Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 3ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810387

Processo nº 0043677-77.2022.8.17.2001

AUTOR: LUCIA DE FATIMA DA SILVA

REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

LUCIA DE FATIMA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA** em face da **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,** igualmente qualificada.

Narra a parte autora que detentora da carteira de nº 00277 0001 7881 0018 e está inclusa na modalidade do Plano Especial Empresarial pela OI/SA (Empresa da qual é funcionária); e, em 2000 teve o seu primeiro diagnóstico de câncer de mama – CID C50 (primeiro câncer) – Neoplasia Maligna da mama. Já, no ano de 2021 teve a sua terceira recidiva e quarto câncer sendo as metástases dessa vez no fígado, pulmão e pleura e, novamente, precisou ser submetida a tratamento quimioterápico para o controle do avanço da doença. Assim, foi diagnóstica com câncer de mama estádio IV por metástases em pulmão e fígado e já foi submetida a toracocentese e pleurodese por volumoso derrame pleural detectado – procedimentos para controle da doença. Ante isso, encontra-se em tratamento médico paliativo, com os medicamentos AROMASIN 25 mg/dia e ABEMACIBLIBE/diariamente, devidamente autorizado pelo plano de saúde, conforme prescrição médica da oncologista Dra. Cristina de Lima Tavares – CRM/PE 13.268, que a acompanha até o presente momento.

Aduz ainda que, em exame de PET/CT, solicitado pela médica oncologista assistente da autora, realizado em 11 de fevereiro de 2022, para avaliação da resposta terapêutica ao tratamento, em comparação ao PT/CT realizado em 26/10/2021, foi evidenciada a progressão da doença pulmonar e hepática, restando inegável a necessidade de novo tratamento para a parte autora devido ao agravamento de sua doença bem como à condição de saúde já debilitada respaldada pela análise clínica. Assim, a médica oncologista, solicitou a realização de Pesquisa de Mutações Somáticas no Gene PKI3CA por NGS, cujo resultado foi positivo, estendido a fim de realizar a análise de todos os genes de risco. E, evidenciando a necessidade de autorização por parte do plano de saúde – empresa ré, para realização do tratamento com as seguintes medicações: **FULVESTRANTO 500 mg (intra muscular) + ALPELISIBE** 300mg **(uso oral)** (SOLAR 01), já que essa combinação é capaz de prolongar a sobrevida livre de progressão em pacientes com mutação do gene PKI3CA, ESTÁDIO IV, CID C50.

Por fim, alega que a empresa ré, em 06 de abril de 2022, apresentou resposta a solicitação administrativa realizada, em 31 de março de 2022, com a negativa ao requerimento de autorização para o tratamento com as medicações: FULVESTRANTO 500MG D1 D14 D28 DOSE DE INDUÇÃO E 500MG IM DOSE DE MANUTENÇÃO A CADA 28 DIAS + ALPELISIBE 300MG/DIA USO CONTÍNUO ATÉ PROGRESSÃO OU TOXICIDADE MÁXIMA, solicitado pela médica, cuja fundamentação para negativa de autorização foi de que o medicamento solicitado não consta no Rol de Procedimentos da ANS, portanto estaria sem cobertura contratual.

Diante do acima exposto, a parte autora propôs a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a empresa ré custeie/forneça imediatamente à Autora o tratamento com as medicações: FULVESTRANTO 500mg D1 D14 D28 dose de indução e 500mg IM dose de manutenção a cada 28 dias + ALPELISIBE 300mg/dia uso contínuo até progressão ou toxicidade máxima, pelo período que a sua médica assistente entender necessário; bem como, seja obrigada a

autorizar e fornecer de imediato quaisquer alterações nas dosagens dos referidos remédios, outros medicamentos e/ou tratamentos relacionados a terapias para o câncer da autora, os quais a sua médica entenda como necessárias, mediante à apresentação da devida requisição e relatório médico. No mérito, a confirmação da tutela, nulidade de qualquer clausula abusiva, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requereu ainda a gratuidade de justiça e a prioridade no trâmite processual.

Decisão, deferindo a gratuidade de justiça, retificando de ofício o valor da causa, e deferindo parcialmente tutela antecipada *perseguida para determinar que a ré, "**no prazo de 72 horas, forneça os medicamentos FULVESTRANTO 500mg D1 D14 D28 dose de indução e 500mg IM dose de manutenção a cada 28 dias + ALPELIZIBE 300mg/dia uso contínuo até progressão ou toxicidade máxima, em rede credenciada do plano Réu, sob pena de multa diária, tudo em conformidade com o que foi prescrito pela médica assistente** (Id 104000056) até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir na hipótese de descumprimento desta ordem judicial, por cada dia de atraso, na forma contida no artigo 537 do CPC, limitado ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de execução das* astreintes".(id 104028704).

Réu devidamente intimado/citado em 28/04/2022 as 10h e 36 min. (id 104149536).

Petição da ré em 02/05/2022, informando o cumprimento da tutela, acostando guia de validação de procedimento. (id 104319584).

Petição da autora ao final do dia 02/05/2022, informando não ter a ré cumprindo com a tutela judicial (id 10442395).

Despacho em 03/05/2022 determinando que a ré" ***COMPROVE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, A PARTIR DESTA INTIMAÇÃO, o cumprimento efetivo da decisão de deferimento de tutela exarada, sob pena de majoração da multa desta feita para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo-se a limitação, sem prejuízo do juízo adotar as providencias que entender necessárias ao fiel cumprimento da medida (art 297 CPC- poder geral de efetivação).*** *Intime-se a autora, de qualquer forma, para tomar conhecimento da guia acostada aos autos." (id 104436683).*

Intimação da ré em 03/05/2022 (id 104536656).

Nova petição da autora informando que a ré permanecesse descumprindo a tutela judicial, A operadora ré autorizou o fornecimento da medicação ALPELIBIZE, 300mg pela clínica prestadora Neoh, a qual informou a autora que realizou a compra efetiva do fármaco no distribuidor, no próprio dia 03/05/2022 e que, no máximo, entre a noite do dia 05/05/2022 e a manhã do dia de 06/05/2022, ela a receberia para iniciar o tratamento. Ocorre que nesta data, ao entrar em contato com a Clínica Neoh, foi comunicada de que a sua medicação provavelmente só estaria disponível no dia 10/05/2022 - ou seja, 4 dias a mais do que a primeira previsão na qual a entrega já se daria com descumprimento do prazo fixado por essa magistrada, conforme fica demonstrado nos prints de whatsapp em conversa com o corpo de enfermagem da Clínica, bem como nos áudios enviados também pelo aplicativo. o que seria considerado de fato o cumprimento da obrigação: a mera autorização ou a consumação da entrega da medicação a beneficiária? Não pode a operadora se esvair da obrigação de fornecimento, apenas, autorizando a concessão e deixar a TOTAL responsabilidade pelo cumprimento sob os comandos da Clínica prestadora. id104822193.

Decisão reconhecendo o descumprimento da tutela, intimando-se o autor para apresentar orçamento da medicação para fins de bloqueio nas contas da operadora ré, id 104862183.

Petição da ré aduzindo que não possui direito legal para comercialização ou estocagem de medicações, portanto, foi preciso a contratação de empresas que são especializadas neste tipo de serviço, em especial, ligados ao fornecimento de medicamentos, para que haja a entrega do medicamento diretamente na residência dos segurados tendo a autora recebido a medicação em 10/05/2022, pugnando pelo reconhecimento do cumprimento da tutela e afastando a incidência de astreintes (id 10526318)

Contestação apresentada na qual suscita preliminarmente : *impugnação ao valor da causa; impugnação `a gratuidade da justiça.* No mérito aduz a ré : **que** existe a necessidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro e a observância das regras contratuais; **que** não há cobertura

contratual para o fornecimento do medicamento e que o mesmo se encontra fora do rol da ANS; **que** a hipótese não comporta a inversão do ônus da prova: **que** não cabe dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido, id105310777.

Réplica ofertada no id 77210944.

Eis o breve relato. DECIDO

Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.355, I do NCPC, tendo em vista que a questão de mérito é unicamente de direito não necessitando de dilação probatória.

Analisando as questões de ordem processual.

A impugnação `a gratuidade merece ser inacolhida.

É cabível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a afirmação de que a parte demandante não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Além disso, o CPC/2015 prevê que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, o juiz determinar a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ao analisar a condição de hipossuficiência da parte, o juízo leva em consideração a situação peculiar de cada caso, avaliando sempre o momento de hipossuficiência vivido pelo requerente, o qual poderá ser reavaliado a qualquer momento, sendo revogado quando e se houver mudança na situação econômico-financeira do beneficiário.

Na impugnação em análise, o impugnante se limitou a alegar que a parte autora não faz jus ao benefício, mas não juntou aos autos qualquer prova suficiente para convencer este Juízo de que o beneficiário não se enquadra na condição preconizada por lei.

A simples alegação do impugnante, desprovida de prova forte e convincente de que o impugnado é dotado de suficientes recursos para arcar com as despesas de uma ação, não se afigura capaz de afastar a presunção legal disponibilizada a seu favor. Ademais, se houve deferimento é porque o juízo processante, não teve dúvidas quanto a aplicação do benefício.

Por tais razões, **deixo de acolher** a preliminar suscitada pela parte demandada.

A impugnação ao valor da causa igualmente merece ser inacolhida, e para tanto, reporto-me ao que já restou fundamentado acerca do tema , constante da decisão id 104028704.

Avanço no mérito.

A relação jurídica existente entre as partes subsume-se a legislação protetiva de defesa do consumidor, sendo oportuno ressaltar que o CDC, inspirado na Carta Magna traz em suas normas elemento axiológico, consistente na defesa do consumidor, erigida na Constituição Federal como direito fundamental (art. 5º, XXXII).

Sabe-se que é direito básico do consumidor a proteção à vida, a saúde e à segurança quando os serviços são prestados deficientemente, consoante dispõe o art. 6º, I do CDC.

OBRIGAÇÃO DE FAZER

Ressalte-se que tal documentação, acima referida, demonstra, conforme descrito na exordial, que a parte demandante foi diagnosticada com doença oncológica e necessidade de tratamento. Ademais, que a autora é beneficiária do contrato de seguro saúde firmado com a demandada, sem carências a cumprir, restando comprovado, conforme laudos médicos anexos, que está acometida da patologia, resultando em graves sequelas.

Ademais, sobre o direito material específico em questão, a lei 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura das doenças listadas na "Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde". É o que se conclui da leitura de seu artigo 10, *caput* e §2º, que traz o chamado "plano-referência", de cobertura mínima devida a qualquer beneficiário do plano:

"Art. 10. É instituído o **plano-referência** de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, **compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil**, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei**, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º ***As pessoas jurídicas*** que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei ***oferecerão, obrigatoriamente***, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo ***a todos os seus*** atuais e ***futuros consumidores.*** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001 c/c ADI 1931, STF)"

O plano-referência, de oferta mínima obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, portanto, ressalvadas hipóteses dos incisos do artigo 10, abarca todos os tratamentos das doenças elencadas com CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Sendo assim, basta que a parte autora, vinculada ao plano de saúde, junte atestado de profissional da saúde habilitado a tanto demonstrando necessidade de tratamento de doença sofrida pelo consumidor para que tenha direito à cobertura do tratamento, o que foi feito no caso em apreço (Id 104000056).

Portanto, a doença da qual padece o beneficiário do plano de saúde e o respectivo tratamento devem ser atestadas por profissional competente para tanto, de livre escolha do paciente, o que é assegurado pela própria lei 9.656/98 (art. 1º, I) e pela RN 428/ANS (art. 5º).

Assim, ao se considerar que a Lei nº 9.656/98, prevê em seu art. 10 a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, além de tratar-se de medicamento de uso parenteral, não vejo razão para a recusa de cobertura na espécie.

Ressalte-se, ainda que, na relação de consumo, o contrato deve ser interpretado da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, consubstanciado no art. 47 do CDC, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a doença restou comprovada, os fármacos são registrados na ANVISA e fora indicado pela médica assistente como única solução para tratar a Autora.

À vista de tais considerações, tenho que o laudo médico e demais documentos apresentados constituem provas inequívocas, suficientes a convencer este juízo da probabilidade do direito, conforme acima mencionado, suficientes a convencer este juízo do direito, conforme acima mencionado, devendo a **tutela para a obrigação de fazer ser mantida ,** não havendo se falar em fornecimento de qualquer outro medicamento ou tratamento que venha a ser requisitado, tratando-se de pedido incerto.

OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de **indenização por danos morais**, este merece guarida, tendo em vista que a frustração de expectativa afeta a dignidade da pessoa humana.

É cediço que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a dano moral indenizável, porém a regra não é absoluta. Assim sendo, é possível ocorrer dano moral diante de eventuais ilícitos de considerável gravidade ou injustificadamente protraídos.

Dessa forma, não se pode negar que em determinados contratos, como os que envolvem planos/seguros de saúde, o inadimplemento pode gerar danos morais aos usuários ,considerando que o objeto contratado abrange a vida e a saúde, bens supremos do ser humano.

De se observar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem considerado que a negativa de cobertura de plano de saúde pode ensejar danos morais, senão vejamos:

*Civil. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Negativa ilegal de cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento médico de emergência. Configuração de danos morais. - N**a esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Recurso especial provido** (Resp907718/ES, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, DJ 07/10/2008)*A recusa da assistência, se deu no momento em que a parte Autora mais necessitava, representando afronta

aos seus direitos de personalidade, pois, embora tenha contratado um plano de saúde justamente para evitar quaisquer complicações no momento em que eventualmente se deparasse com uma situação delicada, viu-se impedida de usufruir de direitos previstos no próprio contrato, para o qual contribuiu. Em casos semelhantes: *PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECUSA INJUSTIFICADA EMCOBRIR OS GASTOS DO SEGURADO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. I - Não se encontra caracterizada a divergência jurisprudencial em razão da dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma colacionado. II - A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir gastos cirúrgicos pode ensejar danos morais. Precedentes da Corte. Recurso especial não conhecido (955716/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, DJ 11/03/2008)Civil.*

Ante as circunstâncias do fato ocorrido, e ainda considerando a extensão do dano, a título de indenização por danos morais, fixo o valor indenizatório na quantia certa **de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**

DESCUMPRIMENTO DA TUTELA- ASTREINTES

-

Como se sabe, a teor do disposto no § 1º do art. 536 do NCPC, a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer justifica-se como meio de coibir o devedor a cumprir a determinação judicial, a fim de atribuir efetividade ao comando, desde que a multa fixada seja pautada nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo como parâmetro o conteúdo econômico da obrigação principal.

A propósito, vejamos os comentários de Nelson Nery Júnior ao aludido dispositivo:

> *"7. Imposição de multa por tempo de atraso. A norma autoriza o juiz a impor multa por tempo de atraso, para que se faça cumprir a determinação do magistrado no sentido de tornar efetiva a tutela concedida. É mais uma alternativa para a efetividade do processo, com natureza jurídica de execução indireta. (...) (NCPC, 16ª edição, p. 1451, nota 7)*

Assim, legitima-se a imposição das astreintes, com o fito de atribuir efetividade a ordem judicial, sem olvidar é óbvio que a multa não pode representar enriquecimento ilícito para o credor, imprescindível pois, observar os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na sua fixação, não obstante se saiba que o parágrafo 1º do art. 537 do NCPC, permita apenas a modificação da multa vincenda.

Na hipótese dos autos, resta demonstrado o cumprimento tardio da decisão, porquanto, embora a ré tenha sido intimada para que " **forneça** (GRIFEI) os medicamentos..." no prazo de 72 horas, isso em 28/04/2022 (id 104149536), efetivamente o remédio apenas repousou nas mãos da parte Autora em 10/05/2022,(vide informação/comprovação do próprio réu,(id 10526320) 08 dias após o prazo.

Resta portanto, demonstrado o atraso de 08 dias no cumprimento da decisão.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** os pedidos para: **a)** confirmar a tutela de id 104028704 ; **b) condenar a ré a** pagar a parte autora indenização a título de danos morais no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** atualizados pela tabela ENCOGE, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento, eis que apenas aqui fixado o *quantum* devido (Súmula 362, STJ e REsp nº 888.751 – BA (20060207513-3) – DJe 27/10/2011[1] - e TJPE[2]. Reconheço 08 dias de atraso no cumprimento da tutela.

Ante a sucumbência mínima, condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 20% sobre o valor da condenação pecuniária, nos moldes do art. 82, §2º, cumulado com o art. 85 (caput), §§2º e 8º, todos do NCPC.

Se interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que o manejo de aclaratórios reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º , do NCPC.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Recife-PE, 22 de agosto de 2022

Valéria Maria Santos Máximo

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VALERIA MARIA SANTOS MAXIMO
22/08/2022 13:16:57
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 112908471

22082213165767200000110392102

IMPRIMIR GERAR PDF